

1501814-87.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... comentários de que tem envolvimento com o tráfico. Ele trabalhava na Câmara dos Vereadores, ajuda a comunidade local com cestas básicas e, as vezes, até "tira do bolso" para ajudar as pessoas do bairro.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, 88,5g de Canabbis sativa L., distribuídos em 51 invólucros, 20,6g de cocaína, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501814-87.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501814-87.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 1360/2021 - 5º Distrito Policial de Piracicaba, 2321205/2021 - 4º Distrito Policial de Piracicaba, 2321205 - 04º D.P. PIRACICABA, 1360/21/528 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Pascoal de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 06h15min, na Rua Deputado Roque Trevisan nº 146, Bairro Mario Dedine, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, tinha em depósito, para fins de tráfico, 88,5g de Canabbis sativa L., distribuídos em 51 invólucros, 20,6g de cocaína, distribuídos em 59 eppendorfs, e 6,3g de cocaína em forma de pedra, distribuídos em 76 invólucros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento e foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica no local acima mencionado, razão pela qual rumaram ao referido endereço. No local, visualizaram no interior da residência uma sacola contendo as drogas acima descritas, pertencentes ao acusado e que se destinavam ao narcotráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 281). Defesa preliminar apresentada às fls. 195/203. Após, a denúncia foi recebida (fls. 219/220) e o réu foi citado (fls. 277).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e as duas arroladas pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa pediu a absolvição, sustentando ilicitude das provas e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do privilégio.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, afasto a tese defensiva de ilicitude da prova em decorrência da realização da diligência policial sem mandado judicial.

A Constituição Federal expressamente autoriza a busca domiciliar sem prévia autorização judicial em casos excepcionais, como aqueles em que há flagrante delito.

Neste sentido dispõe o artigo 5º, inciso XI:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” - gn.

No caso dos autos, havia fundadas suspeitas da prática do crime no local a autorizar a ação da polícia.

De fato, revelou a prova oral que adiante será analisada, que, durante o atendimento de ocorrência de violência doméstica, a qual envolvia a esposa do réu e ainda três crianças, filhos do casal, os policiais tiveram de agir em defesa de um dos menores e, inclusive, em autodefesa quando o acusado tentou agredir um dos agentes com uma picareta. No decorrer dos trabalhos, os policiais ainda tiveram que ingressar no imóvel para fazer a abordagem do réu, que estava muito alterado, e, diante da afirmação feita à policial Carolina pela esposa do réu, no calor dos acontecimentos, de que ele teria arma de fogo (confira-se o documento de fls. 315, no qual em depoimento prestado em outro procedimento, a mulher do réu também fez afirmação neste sentido), não se verifica ilegalidade na ação da polícia de ingressar na casa com o intuito de encontrar esse objeto, momento em que acabaram localizando a sacola com as drogas.

Como se vê, havia fundada suspeita da ocorrência do crime permanente no imóvel, tudo pois a justificar a busca e apreensão sem mandado judicial.

Assim, não há que se falar em afronta à tese firmada em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário 603.616 do C. Supremo Tribunal Federal: “A entrada

forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação penal em razão da ilicitude das provas, notadamente em razão da apreensão de drogas e armas de fogo na residência do paciente, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva. Impossibilidade. Encontro fortuito de provas. Situação de flagrância que autoriza a apreensão de drogas e armas de fogo, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, independentemente da expedição de mandado de busca e apreensão. Prisão preventiva que deve ser mantida. Paciente reincidente. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2089983-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Manuel - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/05/2021; Data de Registro: 18/05/2021).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito, como ocorreu no presente caso, em que o paciente, ao avistar a aproximação dos policiais, empreendeu fuga e pulou o muro da residência para acessar o telhado vizinho, gritando ainda aos comparsas sobre a chegada dos agentes de segurança, tudo a evidenciar que no imóvel estariam sendo praticados ilícitos. Versão, inclusive, que foi corroborada em depoimento policial pelo réu. Diante de tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, pois é evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. 2. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista que o agravante foi preso em flagrante com expressiva quantidade de drogas e vários objetos para endolação e venda do entorpecente - 5.519g de cocaína, balança de precisão, 1500 microtubos plásticos, 600 embalagens plásticas e 4 aparelhos celulares. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 657.088/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - j. 03/08/2021) - g.n.

Afastada, dessa forma, a preliminar arguida, passo à análise do mérito.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

boletim de ocorrência de fls. 09/11;

auto de exibição e apreensão de fls. 12/14;

fotografias de fls. 30/34;

auto de constatação preliminar de fls. 19/24 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 91/93, com resultados positivos para cocaína e maconha em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 07), o réu negou o crime. Disse que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam e sequer estavam em sua residência. Afirmou que durante a madrugada ingeriu bebida alcoólica junto com sua esposa.

Interrogado em juízo (gravação), novamente negou o tráfico. Disse que estava com problemas de relacionamento com a esposa; que já foi assessor de dois vereadores e do ex-prefeito Barjas; já foi candidato a vereador; tinha um projeto com 400 crianças e numa teve drogas em sua casa, apesar de já ter usado entorpecentes na juventude; tinha um acordo com o atual prefeito, mas foi dispensado por ele, e passou a sofrer de depressão a usar remédios psicotrópicos; tem 10 mil seguidores em redes sociais. Quanto ao que ocorreu no dia dos fatos, disse que tomou medicamentos psicotrópicos e dormiu na sala. Acordou com gritos de socorro da esposa, que dizia estar sendo agredida. Ao sair, pegou a picareta porque imaginou que ela pudesse estar brigando com marginais. Quando viu que eram policiais que estavam ali, eles apontaram arma de fogo em sua direção e, assim, soltou o objeto, rendendo-se. Foi algemado e agredido. Os policiais não entraram em sua casa. Encaminhado ao PS, recebeu atendimento médico. Alegou que, durante a pandemia, estava socorrendo uma pessoa com Covid e foi multado por policiais. Fez uma denúncia na Corregedoria da PM e passou a ter problemas. No entanto, nada tem contra os policiais que atuaram na ocorrência em questão, apesar de ter sido agredido por eles. No dia dos fatos, não lhe foram apresentadas drogas. Soube que havia sido preso por tráfico quando teve contato com advogado.

A negativa foi contrariada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03/04) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Silvio Antonio Dutra da Silva declarou que, na data dos fatos, foram acionados, via 190, para atender uma ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, encontraram uma das filhas menores do casal transtornada porque o pai havia batido na mãe. O réu estava dentro da casa totalmente alterado (com pó no nariz, parecendo que tinha acabado de usar entorpecente) e a mulher também estava muito alterada. Tentaram acionar parentes para pegarem as crianças, mas ninguém quis comparecer. Diante disso, acionaram o Conselho Tutelar. A mulher agrediu uma das filhas na presença da guarnição e, quando intervieram para impedir que continuasse a fazer isso, ela alegou que a tinham agredido. O réu se enfureceu e pegou uma picareta para agredi-lo. Conseguiu desarmá-lo. Pediram apoio e, quando o réu entrou na casa para pegar uma pá para continuar a agressão, conseguiram trancá-lo dentro da casa, fechando o portão. Logo depois, chegaram os parentes dele. Quando o apoio chegou, entraram na garagem para pegar o réu, o qual fingiu estar desmaiado. Chamaram a mãe dele para entrarem na casa com eles, mas ela ficou na garagem. Logo na entrada da casa, que estava com a porta aberta, encontraram a sacola com as drogas. Chegaram à conclusão de que as drogas pertenciam ao réu porque havia várias denúncias anônimas anteriores de que ele realizava tráfico no local e ele já foi abordado com arma de fogo. O réu não foi questionado sobre as drogas, porque ele estava sem condições de falar. O Conselho Tutelar também chegou ao local. Não se recordou se a mãe do réu falou alguma coisa sobre as drogas. A esposa do réu disse que as drogas pertenciam a ele. Ela e o réu foram conduzidas ao PS. A esposa do réu só não foi posteriormente conduzida à delegacia porque precisou ficar com as crianças. No PS o réu teve duas paradas cardíacas, mas posteriormente, foi liberado pelos médicos e levado à delegacia. Quando estavam conduzindo o réu para a delegacia, na viatura, mostraram as drogas para ele.

No mesmo sentido as declarações prestadas perante a Autoridade Policial (fls. 05/06) e em juízo (gravação), pela policial militar Carolina Cristina Prado Soares, a qual afirmou que, na data dos fatos, foram ao local para atender ocorrência de violência doméstica. Chegando ali, encontraram a vítima na garagem aparentemente embriagada, muito alterada. O réu também estava na garagem bastante alterado,

parecendo estar sob efeito de drogas. Ele xingava e quebrava objetos no próprio carro que estava na garagem. Ela estava com sangue na bermuda e ele com arranhões. As crianças estavam desamparadas e, em determinado momento, a mulher agrediu a criança mais velha. Determinaram que não fizesse isso e chamaram a menina para fora, onde estavam os policiais. Neste momento, a mulher gritou que a polícia estava interferindo na sua relação com as crianças e o réu, alterado, pegou uma picareta e partiu para cima de seu colega. Conseguiram desarmá-lo. Quando ele entrou novamente na garagem para pegar uma pá para continuar com as agressões, conseguiram fechar o portão, trancando-os do lado de dentro. Chamaram apoio para conseguirem contê-lo. Quando o apoio chegou, o réu estava desmaiado dentro da garagem, ao lado do carro. Neste momento, visualizaram a sacola com as drogas na porta da entrada, a um metro de distancia. No momento em que o apoio chegou, a mãe do acusado, que também foi acionada, também chegou ao local. Antes de o encaminharem ao OS, resolveram fazer uma busca na casa, porque a mulher falou que ele tinha arma de fogo lá. A mãe do réu presenciou a busca, na qual encontraram a sacola com as drogas descritas na denúncia. Declarou, por fim, que a mãe do réu concordou que aquilo seria dele e que chegaram a tal conclusão também porque ele já era conhecido nos meios policiais.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. O próprio réu disse que nada tinha contra esses policiais especificamente.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias,

soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais militares: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos, nem mesmo pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, as quais não presenciaram os fatos e apenas prestaram declarações favoráveis sobre os antecedentes do réu.

De fato, Adriana Broski Rodrigues da Silva, ouvida em audiência (gravação), disse que é vizinha do réu, pessoa conhecida no bairro, e nunca soube que ele tivesse algum envolvimento com tráfico de drogas. Ele trabalhava na Câmara e ajudava a população do bairro, sendo conhecido como "Marcão do Povo". Pelo que sabe, ele não tem nenhum desafeto no bairro ou conflitos com pessoas que pudessem ter colocado a droga na casa dele para prejudicá-lo. Já ouviu brigas e discussões entre ele e a esposa, mas não os viu agredindo as crianças. Por fim, declarou que o portão de frente da casa do réu é fechado, mas tem dois vãos e, se estiver aberto, dá para ver o que tem dentro da sala.

Por fim, Andrea Luana da Silva (gravação), declarou que é vizinha do réu e, no dia dos fatos, viu ele sendo colocado pelos policiais na viatura. Antes disso, estava dormindo e não presenciou o que aconteceu. Conhece-o há onze anos e nunca ouviu comentários de que tem envolvimento com o tráfico. Ele trabalhava na Câmara dos Vereadores, ajuda a comunidade local com cestas básicas e, as vezes, até "tira do bolso" para ajudar as pessoas do bairro.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu tinha em depósito, para fins de

tráfico, 88,5g de Canababis sativa L., distribuídos em 51 invólucros, 20,6g de cocaína, distribuídos em 59 eppendorfs, e 6,3g de cocaína em forma de pedra, distribuídos em 76 invólucros, substâncias estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que as substâncias entorpecentes foram apreendidas no interior de sua residência.

No local, moravam apenas o réu, sua esposa e os três filhos pequenos. Não há como se atribuir a autoria do crime à mulher do acusado, pois, sobre ela, não pesava qualquer fato indicativo de que estivesse envolvida com o comércio de drogas. Situação diversa é a do réu, em relação ao qual havia denúncias anônimas de que estava traficando no bairro.

Neste contexto, não há dúvidas de que as drogas lhe pertenciam.

O destino mercantil dos entorpecentes apreendidos ficou evidenciado em razão da quantidade de drogas, sua diversidade e pelo fato de estarem embaladas em porções individuais, como geralmente são comercializadas.

Registre-se que, ainda que se considere a possibilidade de o acusado ser usuário de drogas, tal condição não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentar o próprio vício e ainda obterem algum lucro.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros – Quantidade incomum com a figura do usuário – Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo – Apreensão de dinheiro – Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal – Denúncia - De rigor a condenação da ré – Absolvição – Impossibilidade – Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO – Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral

- Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e de bons antecedentes (FA e certidões fls. 153/159).

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes, bem assim causas de aumento de penas.

Presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de fixação da pena, possível aplicação do entendimento explanado na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que reconheceu a figura privilegiada nos crimes de tráfico de drogas nos casos de "envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa" (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

Referida decisão foi referendada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, revendo entendimento anteriormente consolidado naquela corte, cancelou o enunciado 512 da Súmula, afastando a hediondez no crime de tráfico privilegiado.

Essas Cortes Superiores têm reiteradamente pronunciado que o tráfico privilegiado, se não forem desfavoráveis ao réu as circunstâncias em que cometido, comporta regime aberto para início do cumprimento da pena e permite sua substituição por restritivas de direitos.

Assim, rendendo-me a tais posicionamentos e, considerando que todas as circunstâncias do crime praticado pelo réu, o qual é primário, lhe favorecem, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal.

Pelos mesmos motivos, substituo tal pena por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena



substituída, e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi duas restritivas de direitos porque a pena substituída é superior a um ano (CP, art. 44, parágrafo 2º) e em razão da maior gravidade do crime, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Neste contexto, substituição por apenas uma pena restritiva de direitos e por uma pena pecuniária muito provavelmente não fariam com que o réu sentisse as graves consequências de seu ato e não seriam suficientes para impedir que continuasse a realizar o nefasto comércio.

Em casos como este, é necessária resposta firme do Estado para que a pena cumpra suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia CONDENO o réu MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA a cumprir um ano e oito meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena substituída, e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Considerando a pena aplicada, incompatível a prisão cautelar, revogo a prisão preventiva decretada e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA